

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4180/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายจังกีหรือจังกี แซ่เตีย
นายชุมพล ทองแก้ว

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 277, มาตรา 279

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 186 (7), มาตรา 214, มาตรา 215

ป.วิ.พ. มาตรา 147

จำเลยได้ถอดกางเกงในของตนออกแล้วจับผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกิน 13 ปี ถอดเสื้อกางเกง จากนั้นพาไปนอนหงายบนฟูกของโจทก์ร่วม จำเลยนอนคว่ำทับ กอดจูบผู้เสียหายและได้พยายามเอาอวัยวะเพศของตนสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ ของผู้เสียหาย อันเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารและพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งอายุไม่เกิน 13 ปี การที่จำเลยได้กระทำอนาจารโดยถอดเสื้อผ้าจำเลยและผู้เสียหายแล้วนอนคว่ำทับ กอดจูบผู้เสียหายและได้พยายามกระทำชำเราผู้เสียหายนั้น เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายที่จะกระทำชำเรา จึงเป็นความผิดกรรม เดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 80, 279, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก 80, 279 วรรคสอง การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นกรรมเดียว ให้ ลงโทษบทหนักตามมาตรา 279 วรรคสอง ดังนี้ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษายกฟ้อง จำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก การที่โจทก์ไม่ อุทธรณ์จึงไม่ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจให้ศาลลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 277 ความผิดฐานนี้ยังไม่ยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก และมาตรา 279 วรรคแรก มิใช่ มาตรา 279 วรรคสองศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจปรับบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดคือ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำอนาจารและพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ซึ่งอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗, ๘๐, ๒๗๙, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายจังกี้หรือจังกี้บิดาผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก, ๘๐, ๒๗๙ วรรคสอง การกระทำความผิดดังกล่าวเป็น กรรมเดียวให้ลงโทษบทหนัก ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง จำคุกจำเลย ๖ ปี ให้ยก คำขอของโจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก, ๘๐, ๒๗๙ วรรคแรกให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา ๒๗๗ วรรคแรก, ๘๐ กับให้ยกคำขอตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ด้วย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รับฟังได้ว่าจำเลยได้ถอดกางเกงในของตนออกแล้วจับผู้เสียหายถอดเสื้อกางเกง จากนั้นพาไปนอนหงายบนฟูกของโจทก์ร่วม จำเลยนอนคว่ำทับกอดจูบผู้เสียหายและได้พยายามเอาอวัยวะเพศของตนสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย อันเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารและพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๓ ปี การที่จำเลยได้กระทำอนาจารโดยถอดเสื้อผ้าจำเลยและผู้เสียหายแล้วนอนคว่ำทับกอดจูบผู้เสียหายและได้พยายามกระทำชำเราผู้เสียหายนั้นเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายที่จะกระทำชำเรา จึงเป็นความผิดกรรมเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง และฝ่ายโจทก์มิได้อุทธรณ์ถือว่าโจทก์ไม่ติดใจให้ศาลลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ ความผิดในฐานนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก จึงคลาดเคลื่อนนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษายกฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก แต่อย่างใด คงพิพากษาว่าความผิดดังกล่าวเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง อันเป็นบทหนัก เมื่อศาลอุทธรณ์เห็น

ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรก และมาตรา ๒๗๙ วรรคแรก มิใช่มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจปรับบทลงโทษจำเลยตามบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดคือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ วรรคแรก ให้ถูกต้องได้ความผิดฐานนี้หาได้ยุติไปแล้วดังที่จำเลยฎีกาไม่

พิพากษายืน.

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายไพศาล รางฆาญ
ศาลอุทธรณ์ - นายสำราญ ชื่นเจริญสุข

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>